

1500266-94.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cássio Henrique Dolce de Faria

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/03/2022

... (condenação por tráfico privilegiado - certidão a fls. 31). É questão polêmica em jurisprudência se a condenação pretérita por tráfico privilegiado gera reincidência específica, no caso de nova condenação por tráfico. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não, porque os crimes têm natureza distinta: Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Jd. Panambi, Santa Bárbara d'Oeste - 13450-515 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500266-94.2022.8.26.0533

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2012441/2022 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 22439476 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 57/22/925 - DEL.POL.PLANTÃO S.BARB.DOESTE, 2012441 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 57/22/925 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE MARQUES BATISTA DE PAULA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Réu Preso

Aos 31 de março de 2022, às 13:30h, em audiência realizada por videoconferência pela 2ª Vara Criminal do Foro de Santa Bárbara d'Oeste, Comarca de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. CASSIO HENRIQUE DOLCE DE FARIA, comigo, escrevente ao final nomeado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, ingressaram na audiência virtual o representante do Ministério Público Dr. Rodrigo Aparecido Tiago, o acusado e o defensor Dr. Rodrigo Salati OAB 284864/SP, todos devidamente intimados e após responderem de forma positiva ao convite enviado pelo programa Microsoft Teams. Em seguida, foi concedida entrevista privada entre o acusado e seu advogado por meio da "sala virtual", com a garantia do sigilo da comunicação, permanecendo os demais em espera. Após a entrevista, houve o retorno deste servidor-organizador, do Magistrado e do representante do Ministério Público à audiência virtual. Como primeiro ato, todos os integrantes exibiram documento de identificação pessoal com foto. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos, etc. 1) Tendo em vista o disposto no Decreto n.º 8.858/16 e na Súmula Vinculante n.º 11, do Supremo Tribunal Federal, justifico que houve manutenção das algemas para a garantia da integridade física de todos os participantes da

audiência, principalmente das pessoas que se encontram na sala de videoconferências do centro de detenção provisória em questão, vez que a segurança daquele local é realizada por reduzido número de agentes. Nesse sentido: “a excepcionalidade do uso de algemas, consignada principalmente na Súmula Vinculante 11, do STF - que dispõe que só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito - não obsta o seu emprego se demonstrados os riscos nela previstos” (STJ, RHC: 39729 SP 2013/0241579-3, relator ministro Moura Ribeiro, julgado em 3 de setembro de 2013). 2) Conforme decidido no H.C. n.º 127.900/STF, determino que o interrogatório do réu seja o último ato da instrução. 3) Esta audiência será realizada excepcionalmente por meio virtual, na forma do Comunicado C.G. n.º 284/2020, diante da pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso de pessoas ao prédio do fórum local, sendo que as gravações serão vinculadas a este termo de audiência”. A seguir, procedeu-se à oitiva de duas testemunhas arroladas pela acusação, bem como ao interrogatório do réu, conforme gravações de áudio e vídeo realizadas através do programa Microsoft Teams, que serão vinculadas a este termo de audiência. Ato contínuo, pelo MM. Juiz foi dito: “Vistos, etc. Declaro encerrada a fase de instrução processual. Aos debates, de imediato”. Depois disso, passou-se aos debates orais em audiência, ainda conforme gravações de áudio e vídeo realizadas através do programa Microsoft Teams, que serão vinculadas a este termo de audiência, sendo que pelo Ministério Público, os principais pedidos foram: a procedência da pretensão inicial, com exasperação da pena-base, em razão da natureza da droga apreendida e de mau antecedente. Na segunda fase da dosimetria, pugnou pelo reconhecimento das reincidências do acusado. Postulou, por fim, a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal, sem substituição, e o perdimento do valor apreendido, enquanto que pela defesa, os principais pedidos foram: a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas, com aplicação da detração imprópria e a extinção da punibilidade. Subsidiariamente, postulou pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime aberto ou semiaberto para cumprimento da sanção corporal, com substituição. Na sequência, o MM. Juiz proferiu a sentença nos seguintes termos: “Vistos, etc. FELIPE MARQUES BATISTA DE PAULA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. E isso porque, segundo consta da denúncia de fls. 1/2, no dia 13 de janeiro de 2022, por volta de 16h30min, na Rua Ângelo Sans, n.º 565, Parque Zabani, nesta cidade e comarca, ele, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, seis microtubos contendo cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O acusado foi notificado (fls. 76) e apresentou defesa prévia (fls. 63/69). Recebida a denúncia (fls. 77/78), ele foi citado (fls. 114). Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas, tendo sido o acusado interrogado, em seguida. Encerrada a instrução, em debates: I) o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão inicial, com exasperação da pena-base, em razão da natureza da droga apreendida e de mau antecedente. Na segunda fase da dosimetria, pugnou pelo reconhecimento das reincidências do acusado. Postulou, por fim, a fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal, sem substituição, e o perdimento do valor apreendido; II) a defesa pediu a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas, com aplicação da detração imprópria e a extinção da punibilidade. Subsidiariamente, postulou pena-base no mínimo legal, reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação de regime aberto ou semiaberto para cumprimento da sanção corporal, com substituição. É o relatório. Fundamento e decido. Não há matéria preliminar pendente de apreciação. No mérito, a pretensão inicial procede, pelos fundamentos expostos a seguir. A materialidade delitiva encontra-se provada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 13/14, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 5, pelo auto de constatação preliminar de fls. 8 e, finalmente, pelo exame químico toxicológico de fls. 99/101. Há, também, há prova suficiente de autoria. Na delegacia, o acusado disse que as drogas apreendidas em seu poder eram de sua propriedade e destinadas ao seu consumo pessoal, pois é usuário de crack e cocaína. Sustentou que o dinheiro que trazia

consigo era proveniente da venda de recicláveis e que estava morando na rua, porque tinha brigado com sua família (fls. 12). Em juízo, ele manteve a tese de que as drogas eram destinadas a seu uso. Acrescentou que sabia que o local em que estava (um bar) era ponto de venda de entorpecentes. Disse que estava no local tomando cerveja e que havia comprado as drogas com ele encontradas naquele mesmo lugar, de um traficante (que descreveu como um menino novo), que se evadiu do local quando viu a viatura. Nesse mesmo momento, junto dele, um casal que também estava no bar teria saído com uma moto. Esclareceu que havia recebido R\$ 160,00 pela venda de reciclagens acumuladas e que havia comprado cada droga com ele encontrada por R\$ 15,00. Finalizou, dizendo que saiu andando quando avistou a viatura porque tem passagens anteriores e sentiu medo de ser abordado com drogas e dinheiro. Como se vê, é fato indubitável que o réu trazia consigo as drogas, recaindo a controvérsia sobre a finalidade mercantil da conduta imputada. Quanto ao ponto, a tese de autodefesa não se sustenta, como se demonstrará a seguir. De início, deve-se mencionar que pesa contra o réu a situação comprometedora derivada de sua prisão em flagrante, trazendo consigo entorpecentes e dinheiro, em conhecido ponto de tráfico. Há, ainda, o relatado pelos policiais militares Isabela e Júlio, que, em depoimentos coerentes, confirmaram, na delegacia (fls. 6/7), que: a) realizavam patrulhamento pelo bairro Parque Residencial Zabani, local conhecido como ponto de tráfico de drogas, ocasião em que avistaram o réu conversando com um indivíduo que lhe entregou dinheiro; b) diante da aproximação da viatura, o indivíduo se evadiu do local rapidamente com uma motocicleta, não sendo possível visualizar a placa do veículo; c) o réu tentou se evadir do local a pé, contudo, a equipe conseguiu abordá-lo na rua Ângelo Sans, em frente ao numeral 565; d) o réu trazia consigo em uma das suas mãos seis eppendorfs de cocaína, bem como a quantia de R\$ 70,00; e) indagado, o acusado informou que os entorpecentes se destinavam à venda; f) diante dos exposto, o acusado foi conduzido para a delegacia. É fato que, em juízo, a policial militar Isabela prestou depoimento absolutamente imprestável, na medida em que, após confundir a ocorrência, ela afirmou não se recordar dos fatos descritos na denúncia. Todavia, ainda assim há prova produzida sob o crivo do contraditório que, quando conjugada com a prova produzida em solo policial, permite juízo de certeza acerca da tipificação mais gravosa da conduta atribuída ao acusado. E isso porque o policial Júlio, em juízo, asseverou, sem dúvida alguma, que: a) o réu foi abordado no momento em que saiu andando, de um comércio. Antes disso, ele estava bem próximo de outra pessoa, que estava numa moto e que saiu, antes da chegada da viatura; b) o local da abordagem é um conhecido ponto de venda de drogas; c) após ser abordado, o réu confessou que estava no local traficando e que o dinheiro com ele encontrado era produto do tráfico. Embora a testemunha Júlio tenha, nesta data, de início, dito que não viu a troca de dinheiro entre o réu e o condutor da motocicleta, quando confrontado sobre essa contradição em suas declarações (após repergunta do Ministério Público), o policial ratificou aquilo por ele dito sobre o pormenor na polícia, de modo que confirmou ter presenciado o ato mercantil. Não há motivo algum para que seja negada credibilidade aos relatos dos policiais militares, com quem o réu não demonstrou a existência de nenhuma animosidade. O depoimento policial harmônico com o restante do conjunto probatório naquilo que importa é suficiente para fundamentar a

sentença condenatória, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Vide, a propósito, o decidido no Habeas Corpus n.º 395.325/SP, pela Quinta Turma daquela Corte, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado em 18 de maio de 2017. Pequenas contradições, referentes a aspectos periféricos da conduta (como a ocorrida no relato judicial da testemunha Júlio), são inerentes ao psiquismo humano e perfeitamente compreensíveis a policiais, que atendem a inúmeras ocorrências similares, em sua rotina. Elas, porém, não têm o condão de minar a credibilidade do declarado pelo policial, até mesmo porque não é crível a suposição de que agente público que tem por dever funcional a manutenção da lei e da ordem viria a juízo mentir (respondendo inclusive penalmente por sua conduta) para incriminar terceiro desconhecido. Cotejando o que foi anteriormente exposto, conclui-se que há conjunto probatório suficiente a escorar a versão acusatória. Não há como, diante desse quadro, ser acolhida a tese de desclassificação da conduta

para uso, porque o contexto (consistente em: situação comprometedora derivada da prisão em flagrante em ponto de venda de drogas, na posse de drogas e de dinheiro + aquilo dito por ambos os policiais na delegacia + aquilo declarado pelo policial Júlio em juízo) evidencia que o réu estava no local dos fatos comercializando entorpecentes. Aliás, nada impede que o usuário de drogas seja, concomitantemente, traficante, o que aparentemente ocorre na situação ora julgada. Por consequência, impõe-se a condenação pela imputação descrita na denúncia. Passo, agora, à dosimetria da pena, em atenção aos vetores específicos do artigo 42, da Lei de Drogas. Foram apreendidas seis porções de cocaína, acondicionadas em microtubos de plástico (fls. 5). A quantidade total de 0,9 gramas de massa líquida de cocaína (fls. 99/101) é tolerada sem exasperação da pena-base pelo que constitui a média da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tanto não procede a tese acusatória de que o encontro de pequena quantidade de cocaína justificaria a exasperação da pena-base que há precedente da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 503.848/MS, no seguinte sentido: "(...) 2. Ainda que considere nociva a natureza da droga apreendida, evidenciada a quantidade não relevante (32,93g de cocaína) e ausentes circunstâncias adicionais - inserção em grupo criminoso de maior risco social, atuação armada, envolvendo menores ou com instrumentos de refino da droga, etc. -, não é razoável a exasperação da pena-base" (relator ministro Nefi Cordeiro, julgado em 27 de agosto de 2019). Por outro lado, verifico que o réu tem contra si três condenações transitadas em julgado. Por isso, uso uma delas, extraída do processo de conhecimento n.º 0003748-71.2015.8.26.0533 (certidão a fls. 31/32 - condenação por receptação, com pena cumprida em 16 de setembro de 2021) como mau antecedente. Registro que: a) essa condenação não será considerada para fins de reincidência, de modo que esta decisão respeita e se mostra de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula n.º 241, do Superior Tribunal de Justiça; b) o Supremo Tribunal Federal decidiu, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 593.818/SC (tema n.º 150), que até mesmo condenações pretéritas prescritas para fins de reincidência são aptas a configurar maus antecedentes. Feitas essas observações, fixo a pena-base um sexto acima do piso, em cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, observo que o réu é birreincidente, tendo em vista suas condenações nos processos de conhecimento n.º 0000236-12.2017.8.26.0630 (condenação por furto qualificado - certidão a fls. 30) e n.º 0002569-34.2017.8.26.0533 (condenação por tráfico privilegiado - certidão a fls. 31). É questão polêmica em jurisprudência se a condenação pretérita por tráfico privilegiado gera reincidência específica, no caso de nova condenação por tráfico. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não, porque os crimes têm natureza distinta: Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 604.376/SP, Sexta Turma, relator ministro Sebastião Reis Júnior, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 17 de setembro de 2020; Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 592.398/SP, Quinta Turma, relator ministro Felix Fischer, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 20 de outubro de 2020. Este entendimento, a que se deve atribuir eficácia persuasiva, deve ser prestigiado. Por consequência, em razão da existência de duas agravantes, aumento as penas até aqui cominadas em um quinto, o que resulta em sete anos de reclusão e seiscentos e noventa e nove dias-multa. Não há atenuantes. Na terceira fase, não há causas de aumento, nem de diminuição. A birreincidência e os mau antecedente do réu vedam-lhe acesso ao benefício do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, por força de texto expresso de lei. Converto em finais, por consequência, as penas anteriormente fixadas. Fixo regime inicial fechado para o cumprimento da sanção corporal, em razão da quantidade de pena imposta e por se tratar de réu portador de reincidências em crimes dolosos e de mau antecedente, o que o torna subjetivamente desmerecedor de regime mais brando. O montante de pena fixado impede a substituição da sanção corporal e a concessão de sursis. Valor unitário do dia-multa no piso legal. Desnecessárias outras observações. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL veiculada por meio da AÇÃO PENAL movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra FELIPE MARQUES BATISTA DE PAULA, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei

n.º 11.343/06, cumulado com o artigo 61, inciso I, do Código Penal. Por conseguinte, condeno-o: I) a cumprir a pena de sete anos de reclusão, em regime inicial fechado; II) ao pagamento de seiscentos e noventa e nove dias-multa, de valor unitário mínimo. Condeno o réu, ainda, ao pagamento da taxa judiciária. Observe-se para a cobrança da taxa, porém, a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, porque ao acusado devem ser deferidos os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. O réu respondeu preso a todo o processo e os requisitos e fundamentos que tinham motivado a sua segregação cautelar apenas são reforçados neste momento. Denego-lhe, por consequência, o direito de recorrer em liberdade. Após o trânsito em julgado: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, comunicando-se esta decisão ao Tribunal Regional Eleitoral; b) expeça-se guia de execução definitiva; c) expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado; d) expeça-se o necessário para a reversão em favor do Fundo Nacional Antidrogas do dinheiro apreendido em poder do acusado, cujo perdimento ora determino, por considerá-lo proveito da ação delituosa; e) autorizo a destruição de eventual remanescente dos entorpecentes apreendidos. Cumpridas as alíneas anteriores, arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Dispensado o registro (Provimento CG n.º 27/2016). Cumpra-se. Nada mais". Em seguida, foi renovado o direito de entrevista privada entre o réu e seu advogado por meio da "sala virtual", com a garantia do sigilo da comunicação, permanecendo os demais em espera. Após a entrevista, houve o retorno deste servidor-organizador, do Magistrado e do representante do Ministério Público à audiência virtual. Pela defesa e pelo sentenciado foi dito haver interesse em recorrer. Por fim, pelo MM. Juiz foi dito: "Vistos, etc. Recebo o recurso interposto pela defesa nesta data, saindo o defensor intimado para oferecer as razões no prazo legal, independente de nova intimação. Após, abra-se vista ao Ministério Público para as contrarrazões. Processado regularmente o recurso, cumpra-se o disposto nos Provimentos n.º 07/2007 e n.º 08/2011, remetendo-se os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens. Anote-se. Expeça-se guia de recolhimento provisória em nome do réu, remetendo-a regularmente instruída à Vara das Execuções Criminais competente". Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do artigo 25, caput, da Resolução n.º 185/13, do Egrégio Conselho Nacional de Justiça. Os presentes saem intimados. Nada mais. Eu, Douglas Beraldo, digitei.

MM. Juiz: (assinado digitalmente).